

1500518-43.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... é conhecido como ponto de intenso tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, foram até o local em viaturas descaracterizadas e avistaram os réus em posição suspeita de tráfico. No local, há venda de um tipo de maconha bem específico, denominado "Bananinha", as quais foram encontradas nos bolsos dos réus. Próximo a eles, a cerca de 2 m, em um arbusto, encontraram mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500518-43.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-43.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055589/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM BALTAZAR ALVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA e WILLIAM BALTAZAR ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 19h00, na Praça do Pedregal, situada na confluência das Ruas Olidair Ambrósio, Albino Manfrim, João Mossim, Pedro Canesin e Guerino Basseti, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, traziam consigo e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 37 (trinta e sete) porções de "Maconha" pesando 140,23g, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, policiais civis da DISE, cientes da constância e da intensidade do tráfico de drogas praticado no endereço supracitado, se dirigiram ao local na

data dos fatos, e, a bordo de viaturas descaracterizadas, observaram a presença de três rapazes que aparentemente aguardavam compradores, decidindo, pois, abordá-los. Eles foram identificados como Gabriel Lopes De Oliveira, William Baltazar Alves e Rian Oliveira dos Santos. Durante revista pessoal, foram encontradas 2 (duas) porções de "Maconha" no bolso da bermuda de William e outras 2 (duas) porções idênticas no bolso de Gabriel, ao passo que, em poder de Rian, não havia nada de ilícito. Em um arbusto situado a cerca de dois metros do local, os policiais localizaram outras 33 (trinta e três) porções de "Maconha" com as mesmas características, totalizando 37 (trinta e sete) porções com o peso bruto de 140,23g. Os acusados informalmente admitiram o tráfico ilícito de entorpecentes, alegando que, em virtude de seu "turno" ter acabado de começar, ainda não haviam vendido nada, razão pela qual não dispunham de dinheiro.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 173/174), os réus foram citados (Gabriel - fls. 189; William - fls. 191) e apresentaram resposta à acusação (fls. 197/198).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo os réus interrogados ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa dos réus requereu a absolvição, por falta de provas, alternativamente, almejou a desclassificação das condutas para o delito previsto no preceito primário do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, em caso de condenação, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo auto de constatação preliminar (fls. 19), pela imagem fotográfica (fls. 18), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 139/141), conclusivo por se tratar de maconha, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os policiais civis André e Marco Aurélio, na fase policial, disseram que, cientes da constância e intensidade do tráfico de drogas na "Praça do Pedregal", Jd Alvorada, especialmente após as 18:00 horas, na data dos fatos, com uso de viaturas descaracterizadas, puderam observar os acusados juntos, aparentemente aguardando compradores de drogas. Diante dos fatos, resolveram abordá-los e revistá-los, ocasião em que foram encontradas com 02 porções de erva aparentando "maconha" no bolso da bermuda de William e outras 2 porções idênticas no bolso de Gabriel. Em poder de Rian nada foi localizado. Ato contínuo, em revista nas proximidades, a cerca de 02 metros dos acusados, num arbusto, localizaram o restante das porções de drogas, também idênticas àquelas já encontradas em poder dos dois primeiros, totalizando 37 porções. Indagados, assumiram informalmente a venda das drogas, inclusive alegando que seu "turno" havia acabado de começar, razão pela qual não estavam com dinheiro, pois ainda não tinham vendido nada. Não quiseram declinar o nome do dono das drogas. Não sabem o motivo de William e Rian estarem, de alguma forma, tentando proteger Gabriel ao alegar que nada teria sido encontrado com ele (fls. 06, 07, 162 e 163).

Em Juízo, André disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de intenso tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, foram até o local em viaturas descaracterizadas e avistaram os réus em posição suspeita de tráfico. No local, há venda de um tipo de maconha bem específico, denominado "Bananinha", as quais foram encontradas nos bolsos dos réus. Próximo a eles, a cerca de 2 m, em um arbusto, encontraram mais drogas, idênticas às encontradas em posse dos réus. Na rua perto dos fatos, estavam apenas os réus e a testemunha Rian Oliveira. Os réus estavam em uma das ruas do Pedregal, local onde a iluminação pública permite a identificação dos réus. Marco Aurélio reiterou o relato de André, acrescentando que encontraram duas porções de droga com William e duas com Gabriel, não tendo encontrado drogas

com Rian. A princípio, os réus disseram que a droga era para uso próprio, contudo, após encontrarem o restante das drogas no arbusto, confessaram informalmente o tráfico, alegando estarem começando seu turno de vendas. Não havia outras pessoas perto do local (v. mídia).

A testemunha Clélia, em Juízo, disse que seu filho é amigo dos réus, os quais frequentam sua residência. Na época dos fatos, morava perto da Praça do Pedregal, local dos fatos. Estava fazendo jantar, quando viu uma luz na varanda, então saiu e viu os meninos "enquadrados". Ouviu os policiais perguntarem de quem era a droga. Disse aos policiais que os três réus trabalham e que a droga não lhes pertencia. Os réus estavam na porta da casa da depoente. Viu que os policiais pegaram 02 "paradas" com Rian e 01 com Willian, sendo que com Gabriel nada foi encontrado. O filho da depoente também estava com os denunciados, e também é usuário de drogas. Seu filho estava apenas com a porção que consumia no momento, mas foi liberado. Pelo que viu, Gabriel não estava com droga. Foi o cachorro quem achou a droga na praça. Primeiro foi encontrada a droga na praça, e depois encontraram a droga com os meninos. Não viu o encontro da droga na praça pelos policiais, mas apenas comentários a respeito (v. mídia).

A testemunha Rian, na fase policial, negou ser traficante de drogas e que estava no local dos fatos para vender tais substâncias. Alega que é usuário de "maconha" e foi até a Praça do Pedregal, conhecido ponto de venda, para adquirir drogas. Comprou duas porções de "maconha" por R\$10,00 cada, de um "moleque". Quanto aos acusados Gabriel e William, são seus colegas, o primeiro não usa drogas, já William também usa "maconha" e comprou uma porção, acreditando o interrogando que fora da mesma pessoa de quem comprou. De repente, chegaram lá os policiais civis, abordaram e revistaram os três, encontrando com o interrogando apenas as 02 porções de "maconha", aquelas que tinha acabado de comprar. Com William, os policiais encontraram 01 porção de "maconha". Com Gabriel, nada foi encontrado. Os policiais já haviam revistado a praça antes de abordarem o interrogando e os outros acusados. Eles mostraram outras porções de drogas que estavam com eles, colocando-as sobre um carro, porém, não pertenciam aos acusados. Na sequência, foram conduzidos à delegacia. Nunca foi preso. Trabalha como montador de válvulas na empresa "MFV" há 02 meses. No dia dos fatos, trabalhou até as 18:00 horas, passou em sua casa e em seguida foi até a Praça do Pedregal. Outras pessoas presenciaram a abordagem, qual seja, a dona da casa em frente a qual estavam, mãe de "Maicon", seu amigo. Estava no local há menos de meia hora (fls. 09).

Em Juízo, disse que é amigo dos réus e no dia dos fatos estavam na casa de Clélia e os três compraram entorpecente para uso. Foi abordado pelos policiais, que encontraram droga com Willian e com o depoente. O depoente estava com duas porções, William tinha uma porção de droga e Gabriel não possuía droga. Os policiais estavam na praça e já chegaram com a droga na mão. Indagaram se a droga lhes pertencia, mas negaram. Não estavam com dinheiro, pois haviam acabado de chegar do serviço. Ninguém confessou informalmente que estava traficando. Comprou sua droga na biqueira que existe na praça, por R\$ 10,00 a unidade. Não sabe onde os policiais encontraram a droga, mas acredita ter sido na biqueira. Clélia viu o momento em que foram abordados e disse aos policiais que os três não fizeram nada. O depoente e os réus trabalham com carteira registrada (v. mídia).

O réu Gabriel, quando interrogado na fase policial, negou que seja traficante de drogas e que estivesse no local dos fatos para vender tais substâncias. Não é usuário de drogas e foi até a Praça do Pedregal, conhecido ponto de venda, apenas para conversar com os amigos. Nega que estivesse na posse de qualquer porção de drogas. William estava com uma porção de "maconha" e Rian com duas. Não sabe onde eles haviam comprado as drogas. Quanto aos acusados Gabriel e Rian, são seus colegas e não estavam fumando "maconha", apenas um outro rapaz que lá estava. De repente, chegaram lá os policiais civis, abordaram e revistaram os três, nada encontrado com o interrogando. Não sabe ao certo, mas os policiais encontram com William e Rian porções de "maconha" nos bolsos, duas porções com um deles e outra porção com o outro. Os policiais já haviam revistado a praça antes de abordarem o interrogando e os outros acusados, não sabendo se eles haviam encontrado mais drogas. Na sequência, foram conduzidos à delegacia. Nunca foi preso (fls. 08).

Em Juízo, disse que tinha chegado do trabalho, foi em casa tomar banho e após na casa da Clélia, mãe de Maicon. Tem o costume de ir lá, pois conhece Maicon, Rian e Willian desde pequeno. Maicon estava fumando e Willian chegou do serviço. Quando o interrogando saiu da casa, pois estava assistindo televisão com Clélia, foram abordados pelos policiais. Alega que todos os três que estavam com ele (Rian, Maicon e Willian) são usuários de drogas, mas o interrogando não usa droga, sendo que nenhum dos quatro comercializam entorpecentes. Trabalha registrado, assim como os corréus. Com Willian havia uma porção de droga e com Rian havia duas porções. Os policiais chegaram da praça com as 37 porções de droga, as quais não pertenciam aos réus. Não sabe de quem eram as drogas apreendidas, acreditando que seja do ponto de venda de drogas. A praça fica há cerca de meio quarteirão da casa em que estavam. Nenhum dos réus confessou informalmente que começaria a vender drogas (v. mídia). O réu William, quando interrogado na fase policial, negou ser traficante de drogas e que estivesse no local dos fatos para vender tais substâncias. Alega que é usuário de "maconha" e foi até a Praça do Pedregal, conhecido ponto de venda, para adquirir drogas. Comprou uma porção de "maconha" por R\$10,00 de um rapaz desconhecido, cujas características não observou, pois estava escuro. Quanto aos acusados Gabriel e Rian, são seus colegas e Rian estava fumando "maconha" junto com o interrogando. Já Gabriel estava apenas conversando, pois não usa drogas. De repente, chegaram lá os policiais civis, abordaram e revistaram os três, encontrando com o interrogando apenas 01 porção de "maconha", aquela que tinha acabado de comprar. Com Rian, os policiais encontraram 02 porções de "maconha", que ele havia comprado ali mesmo, há poucos minutos, do mesmo rapaz de quem o interrogando comprara. Os policiais já haviam revistado a praça antes de abordarem o interrogando e os outros acusados e já haviam encontrado porções de drogas, porém, como já disse, não pertenciam aos acusados. Na sequência, foram conduzidos à delegacia. Nunca foi preso (fls. 10).

Em Juízo, negou a prática delitativa, alegando que havia acabado de chegar ao local, pois estava em serviço, trabalhando como pintor industrial. Chegou ao local, pegou 01 "parada" para fumar e foi até a casa de Clelia, para conversar com um amigo de infância. Os policiais estavam fazendo vistoria na praça, tendo encontrado alguma coisa no local. Foram em direção ao interrogando e demais réus, questionando se a droga lhes pertencia. Encontraram 02 "paradas" com Rian e uma com o interrogando. Negaram a posse da droga encontrada na praça, afirmando que eram trabalhadores, mas mesmo assim foram levados pelos policiais. Clelia saiu de casa para dizer aos policiais que a droga não lhes pertencia, pois não vendem drogas. Comprou a droga na praça, por isso disseram que era embalada da mesma forma que as apreendidas pelos policiais. Não se recorda de quem comprou as drogas, pois há muitos traficantes no local. No momento da abordagem, estavam, em 04 pessoas. Estava com Gabriel, Rian e Maicon, filho de Clélia. Maicon estava fumando quando foram abordados. Gabriel não usa droga. O interrogando, Gabriel e Rian trabalham registrados. Chegou sozinho de moto ao local (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados eram realmente os proprietários da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais civis, tendo conhecimento de que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com uso de viaturas descaracterizadas, avistaram os acusados em atitude típica de comércio de drogas, então resolveram abordá-los e revistá-los. Em revista pessoal, foram encontradas 02 porções maconha no bolso da bermuda de William e outras 02 porções idênticas no bolso de Gabriel. Em revista nas proximidades, acerca de 02 metros dos acusados, num arbusto, localizaram o restante das porções de drogas, também idênticas àquelas encontradas em poder dos acusados, totalizando 37 porções. Os réus, por sua vez, negaram a prática delitativa.

Quanto ao réu Gabriel, este alega não ser usuário de drogas e que estaria no local dos fatos apenas para interagir com amigos, com ele nada de ilícito teria sido

localizado, aduzindo que as drogas foram localizadas com Rian e Willian. A versão, porém, não convence. Os relatos dos policiais civis foram claros e firmes no sentido de localização das drogas com o referido denunciado. Embora o acusado Willian e a testemunha de defesa Rian tenham afirmado que com o corréu não foi encontrada substância entorpecente, é certo que o trio possui relação estreita de amizade, conforme relatado por todos, tornando plausível a confecção de uma versão dos fatos tendente a inocentar o denunciado Gabriel. Ademais, em relatos informais feitos na fase policial, os acusados admitiram o exercício da traficância, esclarecendo a inexistência de quantias em dinheiro no momento dos fatos em razão do início do turno de trabalho. Some-se a isso, o local onde todos foram surpreendidos no dia dos fatos, conhecido pela mercancia de drogas, com informes passados aos policiais civis sobre as condutas típicas em curso.

No que se refere ao corréu William, este rechaça a imputação feita na exordial acusatória, com base em seu vício em entorpecentes e de que as substâncias ilícitas apreendidas pelos policiais civis, próximo ao local onde os acusados estavam, não eram de sua propriedade. Da mesma forma, sua versão posta em sede de autodefesa não convence. Os relatos dos policiais civis foram firmes e claros, com detalhes sobre apreensão das drogas feitas em revista pessoal do acusado e no local dos fatos, as quais possuem as mesmas características, mormente pelo formato de "bananinha", ligando os acusados à propriedade dos entorpecentes. Por outro lado, nenhum dos acusados declinou quem seria o suposto fornecedor das drogas, convergindo para eles o domínio dos ilícitos. Tal como já asseverado, os acusados admitiram informalmente a traficância, declinando inclusive terem sido surpreendidos durante a troca de turnos para venda das drogas, razão pela qual não haviam quantias em dinheiro na posse de ambos.

De arremate, a testemunha de defesa Clélia apresenta relatos contraditórios em confronto com o quanto apurado no inquérito policial.

A testemunha Clélia apresenta um cenário de flagrante feito por vários policiais e a presença de uma viatura de cor preta, quando, ao que consta dos autos, havia apenas uma viatura descaracterizada no momento da prisão e de dois policiais civis, eventos instrumentalizados pelos autos do inquérito policial e não impugnados sequer pelos réus em seus interrogatórios.

Assim, considerando que os réus foram flagrados na posse de significativa quantidade de droga, conclui-se que a droga apreendida era realmente dos réus, bem como destinada à comercialização, notadamente porque não comprovado nos autos o exercício de qualquer atividade remunerada lícita por parte dos réus.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado.

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase

investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200).

Quanto à agravante sustentada pelo Ministério Público, prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, reputo que não incide no caso, por considerar que a pandemia do coronavírus não causou situação de calamidade pública, ainda que formalmente assim decretada por decretos, mas apenas restrição do tráfego de parte da população, e impedimento, também somente em certo período, do exercício de algumas

atividades profissionais. Também não há prova de que o delito teria sido cometido aproveitando-se os acusados da situação de pandemia, ou em razão dela, nem houve descoberta de elementos colhidos durante a instrução processual neste sentido. A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base dos réus no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu Gabriel era menor de 21 anos na época dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Embora os réus tenham admitido a propriedade de parcela das drogas, tentaram justificar suas condutas de forma a legitimar seus atos, motivo pelo qual não podem ser consideradas como admissão de culpa.

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que os réus são primários, também não havendo provas de que integrassem organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização

da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariiedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariiedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é

suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela destruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA e WILLIAM BALTAZAR ALVES, qualificados nos autos, cada qual à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incursa no art. 33, “caput”, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 24 de março de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA